

刑法
No392

共通問題 R4-2

(配点: 2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、乙が熟睡していることに乗じてわいせつな行為をしたが、これに気付いて覚醒した乙から抵抗され、わいせつな行為を行う意思を喪失した後、逃走するため、乙に暴行を加えて負傷させた。この場合、甲に準強制わいせつ致傷罪は成立せず、準強制わいせつ罪と傷害罪が成立するにとどまる。(解答不能)
2. 甲は、自己の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図を有せず、専ら乙を侮辱して報復するため、乙を脅迫して裸にして写真撮影した。この場合、甲に不同意わいせつ罪が成立することはない。(改)
3. 甲は、自らが管理する動画配信サイトにわいせつな動画のデータファイルをアップロードし、同サイトを利用した不特定の顧客によるダウンロード操作に応じて、同ファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータに自動的に送信させ、同コンピュータに記録、保存させた。この場合、甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。
4. 甲は、わいせつな内容を含む書籍を販売したが、その目的は作品の文芸的・思想的価値を社会に主張することであった。この場合、甲にわいせつ文書頒布罪が成立することはない。
5. 甲は、日本国外で販売する目的で、日本国内において、わいせつな内容を含む書籍を所持した。この場合、甲にわいせつ文書有償頒布目的所持罪が成立する。

No.392 共通R4-2	わいせつの罪 3	正答率 83%
------------------	-------------	------------

1 解答不能

本記述では、乙に対して準強制わいせつ罪（旧178条1項）に当たる行為をし、同人に抵抗されてその場から逃走するため同人に暴行を加えて傷害を負わせている。この暴行が準強制わいせつ行為に随伴するものといえるか、これによって生じた傷害結果について強制わいせつ致傷罪（旧181条）が成立するかが問題となり、最決平20.1.22（百選Ⅱ15事件）は、強制わいせつ致傷罪の成立を認めた。令和5年改正法後は、181条（不同意わいせつ等致傷罪）が成立するか、当該暴行が不同意わいせつ行為に随伴するものといえるかを同様に考えることができるが、この問いの前提としては、準強制わいせつ罪（旧178条1項）、強制わいせつ罪（旧176条）、強制わいせつ等致死傷罪（旧181条）という条文構造があることから、解答不能とした。

2 誤っている

本記述は、甲に、不同意わいせつ罪が成立することはないとしている点で、誤っている。

最大判平29.11.29（百選Ⅱ14事件）。判例は、「今日では、強制わいせつ罪〔現：不同意わいせつ罪〕の成立要件の解釈をするに当たっては、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度にこそ目を向けるべきであって、行為者の性的意図を同罪の成立要件とする昭和45年判例の解釈は、その正当性を支える実質的な根拠を見いだすことが一層難しくなっているといわざるを得ず、もはや維持し難い」としている。その上で、「刑法176条にいうわいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには、行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で、事案によっては、当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し、社会通念に照らし、その行為に性的な意味があるといえるか否かや、その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないことになる。したがって、そのような個別具体的な事情の一つとして、行為者の目的等の主観的状況を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難い」としている。この「行為者の目的等の主観的状況を判断要素」について、行為者自身の性欲を満たす性的意図に限られず、被害者に対して性的屈辱感を感じさせることによって復讐等を果たす目的や、第三者らの性欲を満たすための画像等を他人に提供する目的等であっても、社会通念に照らせば、そのような目的によって、当該行為に強い性的な意味が付与されと考えられるので、それらの目的の有無も含めた主観的状況が考慮要素になり得る。本記述の甲は、自己の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図を有していないが、このことから直ちに強制わいせつ罪の成立が否定されるものではない。そして、甲は、専ら乙を侮辱して報復するため、乙を脅迫して裸にして写真撮影しているが、乙が性的屈辱感を感じたのであれば、甲の行為は、176条のわいせつな行為となり得る。したがって、甲に、不同意わいせつ罪が成立することはある。

3 正しい

最決平26.11.25（百選Ⅱ101事件）により、本記述は正しい。

判例は、本記述と同様の事案において、「刑法175条1項後段にいう『頒布』とは、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいう」とした上で、「不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても、その操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によってわいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録、保存させることは、刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の『頒布』に当たる」としている。その理由として、判例は、「被告人らが運営する前記配信サイトには、インターネットを介したダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能が備え付けられていたものであって、顧客に

よる操作は被告人らが意図していた送信の契機となるものにすぎず、被告人らは、これに応じてサーバコンピュータから顧客のパーソナルコンピュータへデータを送信したというべきである」ということを挙げている。本記述の甲は、自らが管理する動画配信サイトにわいせつな動画のデータファイルをアップロードし、同サイトを利用した不特定の顧客によるダウンロード操作に応じて、同ファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータに自動的に送信させ、同コンピュータに記録、保存させているので、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した」といえる。したがって、甲には、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪（175条1項後段）が成立する。

4 誤っている

本記述は、甲にわいせつ文書頒布罪が成立することはないとしている点で、誤っている。

最判昭 55.11.28（百選Ⅱ100事件）。判例は、月刊誌の編集長らが、男女の性的交渉の情景を描写した短編小説「四畳半襖の下張」を掲載した月刊誌を販売した事案において、「文書のわいせつ性の判断にあたっては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、それが『徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの』……といえるか否かを決すべきである。本件についてこれをみると、本件『四畳半襖の下張』は、男女の性的交渉の情景を扇情的な筆致で露骨、詳細かつ具体的に描写した部分が量的質的に文書の中核を占めており、その構成や展開、さらには文芸的、思想的価値などを考慮に容れても、主として読者の好色的興味にうつたえるものと認められるから、以上の諸点を総合検討したうえ、本件文書が刑法 175 条にいう『わいせつの文書』にあたりと認めた原判断は、正当である」としている。本記述の甲は、わいせつな内容を含む書籍を販売しており、その目的は作品の文芸的・思想的価値を社会に主張することであったとしても、主として読者の好色的興味にうつたえるものと認められるのであれば、同書籍は「わいせつの文書」に当たり得る。したがって、甲に、わいせつ文書頒布罪が成立することはある。

5 誤っている

本記述は、甲にわいせつ文書有償頒布目的所持罪が成立するとしている点で、誤っている。

最判昭 52.12.22。判例は、本記述と同様の事案で、わいせつ文書有償頒布目的所持罪（175条2項）における「『販売の目的』〔注：現『有償で頒布する目的』〕とは日本国内において販売する目的をいうものであり、したがって、猥せつの図画等を日本国内で所持していても日本国外で販売する目的であったにすぎない場合には同条後段〔注：現 175 条 2 項〕の罪は成立しない」としている。その理由として、判例は、「刑法 175 条の規定は、わが国における健全な性風俗を維持するため、日本国内において猥せつの文書、図画などが頒布、販売され、又は公然と陳列されることを禁じようとする趣旨に出たものである」ということを挙げている。本記述の甲は、わいせつな内容を含む書籍を、日本国外で販売する目的で所持しているため、「有償で頒布する目的」が認められない。したがって、甲には、わいせつ文書有償頒布目的所持罪は成立しない。